

③

AISYAH BINTI NIK JAAFAR

lwn

SHAHARUDIN BIN MAT NAWI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin Bin Haji Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 2hb. Mei 2018 bersamaan 16 Syaaban 1439 H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0146-2017

[Permohonan Semakan Perintah Interim Secara Interparte]

Peguam Syarie Pemohon : *Zaidi Zain & Associates*

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut seksyen 68 (1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi semakan semula berhubung perintah kes Permohonan No. 10300-038-0192-2017 bertarikh 20/11/2017 yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Selangor Darul Ehsan;
- ii. Bahawa hak jagaan sementara anak yang bernama Karissa Mikaela yang berusia 3 tahun diserahkan kepada Pemohon (ibu);
- iii. Bahawa hak jagaan anak lelaki yang bernama Ariq Mikael yang berusia 8 tahun diserahkan kepada Responden;

- iv. Bahawa hak lawatan dan bersama-sama dengan anak diberikan kepada pihak-pihak pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan kepada pihak yang satu lagi selewat-lewatnya 3 hari sebelum lawatan.
- v. Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah yang mulai ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden di dalam perkahwinan mereka telah dikurniakan dengan dua (2) orang anak iaitu Ariq Mikael bin Shaharuddin yang berusia 8 tahun dan Karissa Mikael binti Shaharuddin yang berusia 3 tahun (selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut).

[3] Pada 21/3/2017, Pemohon telah memfailkan tuntutan hak jagaan kekal anak-anak tersebut melalui saman no. 10300-028-0085-2017 dan masih diperingkat perbicaraan.

[4] Pada 24/3/2017, Responden telah menfailkan permohonan interim hadhanah secara *inter-parte* di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 20/11/2017 telah memerintahkan sebagaimana berikut:-

- a. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak (hadhanah) bernama 1) Ariq Mikael bin Shaharuddin (8 tahun) dan 2) Karissa Mikael binti Shaharuddin (3 tahun) diberikan kepada Pemohon (bapa).

- b. Mahkamah memerintahkan hak lawatan, bersama dan tanpa bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Responden (ibu) pada mana-mana hari daripada isnin sehingga khamis dari jam 6.00 petang sehingga jam 8.00 malam tanpa mengganggu kelas tambahan anak-anak tersebut (jika ada) dengan dimaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon sekurang-kurangnya satu hari sebelum lawatan tersebut hendak dilaksanakan.
- c. Mahkamah memerintahkan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Responden (ibu) pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan dengan diambil pada hari jumaat jam, 7.00 petang dan dikembalikan semula pada Pemohon pada hari Ahad sebelum jam 7.00 petang.
- d. Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) atau pihak berkuasa yang berkaitan memberikan bantuan sewajarnya kepada pihak-pihak dalam kes ini bagi tujuan melaksanakan Perintah ini.
- e. Perintah ini kekal sehingga kes induk hadhanah kes saman no. 10300-028-0085-2017.

[5] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan memfailkan permohonan semakan ini. Berdasarkan kepada Afidavit Permohonan Pemohon hanya terdapat 2 isu sahaja yang dibangkitkan Pemohon bagi menyokong permohonannya iaitu;

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah tidak menimbang secara adil dan berhemah bahawa anak perempuan Pemohon yang bernama Karissa Mikaela yang baru berusia 3 tahun adalah masih kecil dan memerlukan saya selaku ibu kandungnya untuk menjaga dan tinggal bersamanya.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah gagal mengambil kira fakta bahawa Responden (bapa) telah membawa keluar anak-anak dari kediaman asal mereka tanpa pengetahuan dan persetujuan Pemohon (ibu) dan telah menghalang Pemohon (ibu) dari mendapatkan akses ke atas anak-anak tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Secara umumnya permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim sama ada secara *inter-parte* atau *ex-parte* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah adalah merujuk kepada Arahan Amalan No.9 Tahun 2006 sebagaimana berikut:-

....telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.

[7] Walaupun Arahan Amalan tersebut menyatakan perintah yang tidak boleh disemak adalah Perintah *ex-parte*, sedangkan kes di hadapan kami ini adalah Perintah Interim yang diputuskan melalui prosiding *inter-parte*, namun prinsip yang harus diberi perhatian ialah tujuan kenapa ia tidak boleh disemak?

[8] Kami bersetuju bahawa Arahan Amalan itu digubal bertujuan untuk mengelakkan perbicaraan kes induk mengambil masa yang lama kerana diganggu oleh sesuatu prosiding permohonan sampingan. Ianya juga di atas prinsip sesuatu perintah sementara (interim) itu hanya bersifat sementara sahaja sehingga keputusan/perintah muktamad dibuat melalui kes induk.

[9] Di atas prinsip itulah perintah interim *inter-parte* juga tidak dibenarkan disemak **kecuali** jika;

- i. Ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan; atau
- ii. Sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat qatie (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang.

[10] Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kes-kes interim *inter-parte* ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hokum syarak yang bersifat qatie (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana *kes Mohd Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20/9/2010 (belum dilaporkan) dan *kes Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, Kes Mal (Semakan) No.14000-*

003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 yang menyatakan seperti berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[11] Setelah kami meneliti affidavit Pemohon, kami dapati Pemohon telah mempersoalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah yang didakwa Pemohon, telah khilaf apabila membuat keputusan tanpa mengambil kira Pemohon sebagai seorang ibu yang mempunyai taraf *status-quo* hadhanah dan merupakan orang yang paling layak untuk menjadi hadhinah kepada anak perempuan yang berusia 3 tahun dari segi undang-undang dan hukum Syarak.

[12] Oleh yang demikian, kami perlu menilai samada keputusan Hakim Bicara tersebut salah aturan yang nyata berdasarkan undang-undang dan hukum Syarak kerana Pemohon dalam affidavitnya ada menyatakan bahawa Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah gagal mempertimbangkan apabila meletakkan penjagaan sementara kedua-dua anak tersebut kepada Responden.

[13] Kami memanggil dan menyemak rekod kes mal no. 10300-038-0192-2017, kami dapati Hakim Bicara telah bertindak mendengar permohonan di dalam prosiding *inter-parte* dengan permohonan interim ini dimulakan oleh Responden pada 24/3/2017. Ketika kes permohonan interim masih dalam prosiding, Pemohon telah membawa anak kedua (P) yang berusia 3 tahun tinggal bersama dalam jagaannya manakala anak pertama (L) yang berusia 8 tahun berada dalam jagaan Responden. Pada prosiding terakhir bertarikh

20/11/2017, Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah telah membacakan keputusan yang telah mengecewakan Pemohon kerana hak jagaan sementara kedua-dua anak tersebut telah diberikan kepada Responden.

[14] Berhubung dengan isu hak jagaan anak, suka kami merujuk kepada subseksyen 82(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enak. No.2/2003*] yang menyatakan:-

Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan

Ini bermaksud *status-quo* hadhanah seseorang anak yang masih kecil ialah di bawah penguasaan ibunya sehinggalah pihak penentang berjaya membuktikan di Mahkamah bahawa sifat-sifat ibu di masa-masa yang material bertentangan dengan seksyen 83 dan membuktikan hak seseorang perempuan terhadap hadhanah telah hilang sebagaimana kehendak seksyen 84 enakmen yang sama.

[15] Peruntukan ini adalah menepati kehendak hukum Syarak. Di dalam kitab *Kifayatul al Akhyar*, karangan Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, (ulama' pengikut mazhab Syafei kurun kesembilan Hijrah), juzuk 2, muka 93, cetakan Sulaiman Marie, Singapura, ada menyebut:-

وهي نوع من الولاية إلا أنها بالإناث أليق، لأنهن أشفق وأهدى إلى
التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال، ومؤنة
الحضانة على الأب، لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة، فإذا فارق
الرجل زوجته فالأم أحق بحضانة الولد منه، ومن النساء باشر وط

Yang bermaksud:

“Hadhanah adalah sejenis kuasa, kecuali atas sebab-sebab yang tertentu, diberi kepada perempuan kerana mereka lebih menaruh kasih sayang kepada kanak-kanak, lebih tepat untuk mendidiknya, lebih sabar dalam melaksanakan tugas memelihara kanak-kanak dan perempuan juga sentiasa lebih banyak bergaul dengan kanak-kanak. Pembiayaan hadonah tertanggung ke atas bapa kerana pembiayaan hadonah itu adalah diperlukan sama seperti nafkah. Apabila seseorang lelaki bercerai dengan isterinya, ibu (isteri itu) adalah lebih berhak mendapat hak hadonah anak pasangan itu daripada bapa anak itu, dan daripada wanita-wanita yang lain dengan beberapa syarat.”

[16] Keutamaan ibu yang paling layak adalah berdasarkan sebab ibunya lebih menaruh kasih sayang, lebih sabar mendidiknya, membelainya manja, lemah lembutnya, lebih merinduinya dan sebagainya. Kesemua sifat-sifat yang ada pada diri ibu tersebut sebenarnya adalah demi kemaslahatan anak tersebut bukannya kemaslahatan ibu penjaganya. Ini bertepatan konsep hadhanah yang mana dijelaskan oleh Sayed Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 8 :

إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة ، إلا أن حق
المحضون اقوى من حق الحاضنة

Yang bermaksud:-

“Sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak di dalam hal pemeliharaan tetapi hak yang dijaga(anak) lebih kuat daripada hak yang menjaga”.

[17] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, kami merujuk kepada alasan penghakiman Hakim Bicara dan kami dapati Hakim Bicara telah tidak memberikan apa-apa alasan atau justifikasi kenapa memerintahkan hak jagaan sementara kedua-dua anak tersebut yang berusia 8 dan 3 tahun diberikan kepada Responden (bapa) sedangkan peruntukan subseksyen 82(1) *Enak. No.2/2003* di atas nyata bahawa anak yang masih kecil adalah bersama ibunya.

[18] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak apabila membuat keputusan tanpa memberikan apa-apa alasan atau justifikasi serta tidak merujuk kepada peruntukan-peruntukan yang berkaitan. Oleh yang demikian adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap perintah hak jagaan sementara yang bertarikh 20/11/2017 tersebut.

[19] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk...

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10300-038-0192-2017, **MAKA** Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- i. Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA.**
- ii. Perintah kes mal no. 10300-038-0192-2017 bertarikh 20/11/2017 **DIBATALKAN.**
- iii. Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Di Shah Alam hendaklah **DISEGERAKAN.**

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **Y.A.A DATO' MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A DATO' YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor